

1500169-85.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... - certidões de p. 40 e 181); roubo majorado (autos n.º 1521878-

81.2017.8.26.0562 - certidões de p. 42 e 181); violação de direito autoral (autos n.º 0010918-80.2010.8.26.0562 - certidões de p. 41 e 181); e roubo simples tentado (autos n.º 0021635-83.2012.8.26.0562 - certidões de pp. 41/42 e 180).

Além disso, ostenta condenação definitiva antiga pelo crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500169-85.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500169-85.2022.8.26.0536 - Controle n.º 037/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO GOMES DE MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

Vistos.

MARCELO GOMES DE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II (terceira figura) e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 2h30min, na Praça Martins dos Santos, Jabaquara, nesta cidade e Comarca, juntamente com outros dois indivíduos, os quais não foram identificados, de comum acordo, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, caracterizadores do concurso de pessoas, e mediante esclada, tentou subtrair, para si, fios de cobre pertencentes à Prefeitura Municipal de Santos, somente não consumando a infração por circunstâncias alheias a sua vontade.

Diz a denúncia que o acusado, na companhia de outros dois indivíduos não identificados e que o auxiliavam no sucesso da empreitada delitiva, por meio de esforço incomum, escalou o poste de energia elétrica, no desiderato de subtrair fios de cobre.

Durante a execução do delito, funcionário do sistema de monitoramento de câmeras informou aos guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina que três indivíduos estariam subtraindo fiação de um poste.

Os guardas se dirigiram ao palco dos acontecimentos e verificaram que dois indivíduos permaneciam embaixo, enquanto o acusado estava pendurado no poste e realizava a retirada dos fios de cobre.

Com a aproximação dos guardas municipais, dois dos indivíduos fugiram em direção ao morro. O acusado saltou do poste e empreendeu fuga em direção à estação rodoviária, mas foi perseguido e detido.

Realizada busca pessoal, localizou-se com o réu um alicate e uma faca de cozinha. Além disso, no local, os guardas apreenderam uma mochila contendo outras três facas, uma chave de boca pequena e um alicate. Os outros dois indivíduos não foram localizados.

Diz, por fim, a petição inicial que, apesar do rompimento da fiação, o acusado e os outros indivíduos não lograram êxito na subtração dos fios, em razão da rápida intervenção dos guardas municipais (pp. 82/83).

Recebida a denúncia (pp. 84/85), foi o réu citado pessoalmente (p. 101). A Defesa ofereceu a resposta de p. 124, prosseguindo-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (pp. 127/128).

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas, procedendo-se ao interrogatório (pp. 185/186).

Em alegações finais, por memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na inicial. Ainda, pretendeu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do réu. Além disso, pleiteou o reconhecimento da agravante da reincidência, argumentando que a condenação pelo crime de roubo majorado justifica maior reprovação em sua conduta, bem como a aplicação da causa de diminuição da pena em razão da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), pois a conduta chegou perto da consumação. Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência (pp. 220/226).

A Defesa, em suas derradeiras alegações escritas, pleiteou a absolvição pela insuficiência probatória, sustentando que a confissão não pode ser considerada isoladamente e que não foram juntadas as imagens do ocorrido captadas pelo sistema de câmeras da Prefeitura Municipal, embasando-se o pedido de condenação exclusivamente nos depoimentos dos guardas municipais, que devem ser considerados suspeitos. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, asseverando que a consideração das condenações antigas ofende o princípio da proscrição da perpetuidade das penas e da humanidade das penas, e que não se pode confundir personalidade e conduta social com antecedentes criminais. Além disso, pretendeu o reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência. Ademais, argumentou que não incide no caso a majorante do repouso noturno, por se tratar de furto qualificado, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.087). Por fim, requereu a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa no patamar máximo legal e a fixação do regime inicial semiaberto (pp. 235/248).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade da infração penal está demonstrada no auto de exibição e apreensão de p. 10 e no laudo de pp. 227/232.

A autoria também é certa.

Ao ser preso em flagrante delito, o acusado manteve-se calado, deixando de esclarecer as razões e circunstâncias que ensejaram sua prisão (p. 6).

Em juízo, ao ser interrogado, o acusado admitiu a prática de conduta criminosa, nos seguintes termos (pp. 208/214):

J.: Boa tarde.

D.: Boa tarde.

J.: O seu nome é Marcelo Gomes de Moura?

D.: Sim.

J.: Sei que o senhor está preso em razão de uma outra condenação e me lembro que o senhor já foi processado por outros fatos, é isso mesmo?

D.: Correto.

J.: Sem ser pelos processos desse ano, o senhor tinha ainda alguma pena a cumprir?

D.: Eu estava assinando ainda, que um tempo atrás aí eu estava devendo, só que o fórum não deixava a gente assinar por causa da pandemia.

J.: E assinar era por algum processo em andamento ou por condenação?

D.: Porque eu ganhei a minha liberdade, ganhei a minha condicional, aí todo o mês tinha que assinar.

J.: O senhor sabe se ainda tem pena a cumprir ou estão todas cumpridas?

D.: Se não me engano eu tenho para ficar na rua assinando ainda, sete, oito a nove anos, algo assim, que o artigo era 157.

J.: Roubo então?

D.: Sim.

J.: Afora isso o senhor tem outras condenações de outros tipos de crime?

D.: Não.

J.: O senhor conhece os guardas que nós ouvimos hoje, Mário e Luan?

D.: Me recordo.

J.: Tem alguma coisa contra eles?

D.: Tenho nada contra eles não.

J.: A acusação aqui é de uma tentativa de subtração, consta aqui que... (Lida a Denúncia), o senhor tem interesse em responder às perguntas que vão ser feitas?

D.: Sim.

J.: É um direito seu não responder, tudo bem?

D.: Sim.

J.: Essa acusação é verdadeira, não é verdadeira, o que aconteceu nesse processo?

D.: Nesse dia, eu mesmo sou usuário de droga, uso química, tenho residência fixa e tudo, meu pai mora no morro e me deu uma casa no morro, mas conforme eu uso uma droga que é muito forte, eu não consigo ficar em casa, eu saio para tomar conta de carro e fazer reciclagem. Realmente no dia desse acontecido eu estava com o meu carrinho de mercado indo reciclar, que as pessoas das lojas de Santos me conhecem, que eu entrego todo final de mês uma sacola para eles com material fino para reciclar. Quando eu estava descendo, encontrei esses dois amigos que já encontrei na vida da droga, conheci usando droga. Foi quando eles falaram que dava para fazer um dinheiro rapidinho e eu acabei me levando pelo efeito da droga e acabei cometendo esse delito, senhora.

J.: O senhor se lembra do que fez?

D.: Eu não me recordo direito, só me recordo que eles falaram “fica na esquina, que se a polícia vir você assobia” e pegou, levei meu carrinho lá para o outro lado do túnel, fiquei no meio dos dois túneis, aí um subiu e o outro ficou cortando embaixo.

J.: O senhor subiu em algum lugar?

D.: Não me recordo disso não. Só me recordo que fiquei no meio dos dois túneis com o carrinho e um subiu e o outro cortando embaixo.

J.: O senhor não se lembra de ter subido no poste?

D.: Não me recordo, me recordo que estava no meio do túnel quando veio a guarda municipal.

J.: O senhor foi alcançado no meio do túnel, mas o que fez antes não lembra?

D.: Não me recordo, estava sob efeito de droga.

J.: E as pessoas que estavam com o senhor, conheceu da rua?

D.: Sim, usando droga, da rua mesmo.

J.: A ideia era conseguir fios para vender e conseguir mais drogas, é isso?

D.: Isso mesmo.

J.: O senhor disse que tem uma casa no morro que seu pai lhe deu. É lá que mora a sua família?

D.: Sim, na rua Santa Elizabeth, nº 1558.

J.: Nessa casa o senhor mora com a família. O senhor é casado, tem mulher, filhos?

D.: Eu tenho dois filhos, mas eu não estou mais com a minha mulher.

J.: E onde estão os seus dois filhos?

D.: Meu filho hoje fica um com a minha mãe e a outra com ela, que nós separamos.

J.: Com a sua ex-mulher, é isso?

D.: Sim.
J.: Que idade tem seus filhos?
D.: O Bruno vai fazer agora dezoito e a Vitória vai fazer catorze.
J.: O senhor usa droga há quanto tempo?
D.: Desde os dezesseis anos.
J.: Sempre usou maconha, cocaína, qual tipo de droga usa?
D.: Já usei cocaína, crack, maconha, bala, lanças.
J.: E atualmente usa qual?
D.: Eu estava usando na rua agora bastante crack, estava afundando no crack.
J.: Desde que foi preso não usou mais drogas?
D.: Não usei mais drogas, mas consegui ficar na rua dois anos e oito meses sem usar também, que o meu pessoal quer vender tudo e ir para Belo Horizonte, que a minha família tem uma fazenda lá e quer sair daqui.
J.: O senhor se lembra de estar com uma mochila que tinha ferramentas no interior dela?
D.: Não.
J.: Facas, ferramentas, nada disso?
D.: Não, eu não preciso andar com isso, o que eu andava dentro do meu carro era um alicate de eletricitista, que sempre precisava para tirar os parafusos para separar o alumínio do ferro, então eu sempre andava com o alicate.
J.: Quando senhor chama de carro, que tipo de carro é?
D.: Carrinho de mercado, de ferro.
J.: Que o senhor empurra na rua?
D.: Isso.
J.: O senhor estudou até que ano na escola?
D.: Até a quarta série, que eu conheci a droga muito cedo, aí parei de estudar.
J.: Alguma coisa a mais para me dizer além do que lhe perguntei?
D.: Não.
Dada a palavra ao Ministério Público, nada foi perguntado.
Dada a palavra ao Defensor Público, nada foi perguntado.
J.: Encerrado.
E, ao que se vê do processado, é certo que a prova aqui reunida dá sustento à condenação, pois se revela firme, segura e coerente.
Luan Silva de Oliveira, guarda municipal, ao prestar depoimento em juízo, contou (pp. 194/197):
MP.: Boa tarde.
D.: Boa tarde.
MP.: O que aconteceu nesse dia, nesse local?
D.: Estávamos em patrulhamento, fomos acionados sobre uma parte que estava em cima do poste tentando furtar fios de cobre e duas partes embaixo auxiliando essa parte que estava em cima do poste. Nós nos deslocamos até o local, quando chegamos avistamos as duas partes que estavam embaixo e quando elas avistaram a chegada da equipe se evadiram. O que estava em cima do poste pulou e se evadiu também. Nós realizamos o acompanhamento do mesmo e conseguimos capturar ele na rua Amador Bueno.
MP.: Ele tinha algum objeto que possibilitasse ter subido no poste, como foi isso?
D.: Objeto escada, não me recordo de ter, ele deve ter escalado o poste. Lembro que encontramos alguns materiais com ele.
MP.: O senhor poderia dizer quais foram os materiais que o senhor encontrou com ele?
D.: Se não me engano foram 4 facas, alicate e chave de fenda.
MP.: Ele chegou a conseguir cortar a fiação?
D.: Sim, conseguiu a parte de baixo, mas não conseguimos avistar a parte de cima se ele havia conseguido cortar ou não. Como era alto, não tinha visualização, mas a parte de baixo estava cortada sim.
MP.: E esses fios estavam no local?
D.: Sim.
MP.: Ou foram levados pelos outros?
D.: Não, eles não conseguiram. Como a equipe chegou eles se evadiram.

MP.: E o que ele disse para vocês quando foi abordado?
D.: Ele se entregou e não falou mais nada.
MP.: Ele não chegou a dizer quem eram aqueles dois indivíduos que estavam com ele?
D.: Tentamos indagar, mas ele falou que não conhecia. Só falou que estava ajudando.
MP.: Esse poste, cuja iluminação ele tentava tirar a fiação, fica localizado onde exatamente?
D.: Na saída do túnel, na avenida Valdemar Leão e ali é num local onde toda hora está tendo furto.
MP.: Quando corta a fiação dali, o que ocorre com o local?
D.: Normalmente apaga ali nas proximidades.
MP.: Essa iluminação está saindo do túnel que o senhor mencionou?
D.: Não, essa iluminação é do poste que está na saída do túnel.
MP.: O senhor já conhecia ele?
D.: Não.
MP.: Sem mais perguntas.
Dada a palavra ao Defensor Público, nada foi perguntado.
J.: Encerrado.
De igual maneira, o guarda municipal Mário Bruno dos Santos disse na fase judicial:
MP.: Boa tarde.
D.: Boa tarde.
MP.: O senhor se recorda do que aconteceu nesse dia, nesse local?
D.: Sim.
MP.: O senhor poderia informar como teve conhecimento do fato, o que foi lhe passado, se o senhor foi ao local, o que aconteceu ali?
D.: Então, como no histórico acho que tanto a senhora como a doutora deve ter acesso eu faço parte dessa ocorrência, então as duas viaturas foram acionadas, porém uma viatura foi para um sentido, onde as outras duas partes foram e uma viatura foi para onde o Marcelo foi, só que a gente não conseguiu deter essas duas outras partes, porque eles acessaram para o outro lado do morro, que é do São Bento. O Marcelo seguiu sentido rodoviária, sendo detido pela outra viatura. Quando a gente retornou para o ponto onde já haviam detido o Marcelo, ele já estava detido dentro da viatura, porque foi muito rápido, a gente foi atrás das duas partes, a gente não conseguiu pegar até porque subiram o morro e se a gente fosse poderia ter confronto.
MP.: O senhor chegou a ir ao local na hora que foi passado a ocorrência? O senhor chegou a ver efetivamente onde estava o Marcelo antes dele fugir e os outros elementos fugirem?
D.: Foi tudo monitorado, porque a gente tem o nosso sistema de monitoramento.
MP.: Mas o senhor viu?
D.: Pelas imagens do monitoramento sim.
MP.: O que ele estava fazendo, onde ele estava?
D.: Estava em cima do poste.
MP.: E os outros dois?
D.: Estavam na parte de baixo esperando, não sei se ele cortar o fio ou tirar o holofote, aí já não posso dizer para a senhora, porque no momento que a gente estava chegando no local, que as duas partes perceberam, já se evadiram, ele já desceu do poste rapidamente e já se evadiu sentido rodoviária. Onde a gente foi atrás das duas outras partes, aí já não sei no decorrer do caminho.
MP.: O senhor sabe dizer se foi encontrado algum objeto lá no local?
D.: Ferramentas para pode utilizar, ferramentas de corte, tinha um tipo de marreta, uma faca grande e tinha também uma bolsa que foi encontrada.
MP.: Tinha fios cortados lá no local?
D.: Sim, o fio foi cortado, mas não conseguiram subtrair.
D.: Pelo o que a gente visualizou ali a parte de cima do poste, só que em volta tinha uns fios ali no chão também que foram arrancados.
MP.: O senhor sabe dizer se alguém daqueles que fugiram conseguiram levar alguma fiação?
D.: Não dá para saber, uma que a gente não deteve as partes para poder alegar que tinha algum produto, então não dá para saber se conseguiram subtrair algum objeto e

até fio.

MP.: O senhor chegou a conversar com o acusado?

D.: Não, porque quando cheguei na situação ele já estava algemado e na viatura. A gente só conduziu.

MP.: O senhor já conhecia ele?

D.: Não, mas recentemente teve uma outra ocorrência com ele já.

MP.: O senhor não conhecia então?

D.: Essa situação da rodoviária foi a primeira vez que conheço o senhor Marcelo.

MP.: Sem mais.

Dada a palavra ao Defensor Público, nada foi perguntado.

J.: Encerrado.

Vê-se assim, que o contexto probatório aqui amalhado se revela coerente, harmônico e uníssono, dando ensejo ao desate condenatório.

Os depoimentos dos guardas municipais são seguros e não há contradição capaz de retirar valor do contexto probatório, que revela que a confissão manifestada pelo acusado na fase judicial não poderia ser desprezada.

Sob o crivo do contrário, os guardas municipais foram firmes e coerentes, não se evidenciando mácula em seus relatos. Ao revés, narraram que o setor de monitoramento eletrônico da cidade informou, via rádio, que indivíduos estariam furtando os fios de um poste de iluminação pública.

Assim, foram ao local e viram o acusado pendurado no poste tentando subtrair a fiação, enquanto outros dois indivíduos permaneciam embaixo. Ao perceberem a presença da Guarda Municipal, os três homens fugiram, mas o réu acabou detido, sendo com ele e nas proximidades do poste localizados instrumentos como facas, alicate e chave de fenda.

Relataram, ainda, que os criminosos conseguiram cortar a extremidade do fio que estava na superfície do solo, mas não souberam informar se os agentes conseguiram cortar a extremidade que estava na parte superior do poste de iluminação.

Tudo indica que os guardas municipais agiram com lisura ímpar e, por certo, não se poderia desacreditar relato de cada qual, não se podendo entender como suspeitos aqueles que são investidos de poder para tal função.

E, como já se decidiu:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (HC 87662, Rel. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007).

"... A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário..." (TJSP; Apelação Criminal 1500453-63.2018.8.26.0559; Rel. Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021).

O réu, por sua vez, admitiu sua participação na conduta delituosa, dizendo que ficou encarregado de vigiar a aproximação da Polícia, ao passo que um de seus comparsas escalou o poste de iluminação e o outro permaneceu cortando a extremidade do fio na superfície do solo.

Disse, ainda, não se recordar se escalou o poste de iluminação, uma vez que estava sob efeito de droga.

Assim, patente que não se tem fundamento que autorize a absolvição, pois é certo que a prova aqui colhida bem indica que o réu tentou subtrair os fios de cobre do poste de iluminação.

Inegável que se tratou de subtração tentada, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu e seus comparsas, que se viram surpreendidos pelos guardas municipais.

Outrossim, ao que se vê da sólida prova oral, a qualificadora relativa ao concurso

de pessoas é situação configurada, pois é de se reconhecer que o réu e os dois indivíduos não identificados estavam efetivamente ajustados, atuando com inequívoca divisão de tarefas e apoio mútuo para a consumação da subtração.

E, como já se decidiu:

"...O ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual todos aqueles que concorreram para o crime incidem nas penas a ele cominadas, pois é tido como coautor todo o agente que desempenha tarefa necessária ao êxito global da infração. Para a caracterização da coautoria no concurso de pessoas é necessário somente a colaboração do agente para o deslinde da prática delituosa, não se exigindo que todos os partícipes tenham consumado atos típicos de execução..." (TJSP; Apelação Criminal 1503167-16.2018.8.26.0229; Rel. Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 11/06/2020). A qualificadora da escalada também se caracterizou.

Conforme relato consistente dos dois guardas municipais ouvidos na fase judicial, o réu escalou o poste de iluminação, empregando esforço incomum para a prática da subtração, situação hábil à caracterização da qualificadora.

Não bastasse, é certo que o laudo pericial de pp. 227/232 apontou que: "Junto ao poste examinado, presos por uma haste metálica, a uma altura aproximada de 3,5 m (três metros e cinquenta centímetros), foram observados marreta e faca de cozinha serrilhada."

Certo está que o acusado e seus parceiros valeram-se de especial destreza e meio não comum para alcançar os fios de cobre, localizados a altura considerável do chão como bem se sabe, sendo forçoso reconhecer que demonstrada se tem a qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.

Por assim ser, em sendo firme e seguro o contexto probatório, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório, há suporte indicando o desate condenatório. Procede, portanto, a ação penal.

Passo à individualização da pena.

Inicialmente considere-se que há duas qualificadoras comprovadas – concurso de agentes e mediante escalada – sendo utilizada a primeira para qualificar o crime e migrada a segunda para as circunstâncias judiciais; do contrário, uma das qualificadoras seria desprezada e não é correto punir um furto duplamente qualificado com a mesma pena de um furto qualificado.

O acusado é reincidente, uma vez que definitivamente condenado por: furto (autos n.º 0005763-23.2010.8.26.0554 – certidões de p. 40 e 181); roubo majorado (autos n.º 1521878-81.2017.8.26.0562 – certidões de p. 42 e 181); violação de direito autoral (autos n.º 0010918-80.2010.8.26.0562 – certidões de p. 41 e 181); e roubo simples tentado (autos n.º 0021635-83.2012.8.26.0562 – certidões de pp. 41/42 e 180).

Além disso, ostenta condenação definitiva antiga pelo crime de roubo majorado (autos n.º 0016419-15.2010.8.26.0562 – certidões de p. 41 e 180), a qual, ainda que não sirva para configurar a agravante da reincidência, ante o decurso do quinquênio legal, continua a macular sua vida pregressa e deixa claro que a situação pessoal do acusado difere daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em prática criminosa.

Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 593.818, fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", decidindo que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"... No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes..." (AgRg no HC 509.034/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em

06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Registre-se, outrossim, que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente..." (AgRg no AgRg no AREsp 1576730/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 19/10/2021).

Assim, levando em conta os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em especial em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias desfavoráveis do crime, pois o furto foi praticado mediante escalada, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência, representada por quatro condenações definitivas por crimes como roubo simples e majorado, furto e violação de direito autoral, o que não poderia ser desprezado, agravo a pena em 1/2 (metade), fixando-a em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Consoante estabelece o artigo 67 do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, preponderam as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Não se olvida da existência de julgados recentes, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, adotando o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea seriam circunstâncias igualmente preponderantes.

No entanto, de acordo com o entendimento tradicional, e ainda, majoritário, inclusive adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a reincidência é circunstância subjetiva de maior prevalência.

A respeito decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"... REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal." (RHC 141519, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, processo eletrônico dje-223 divulg 08-09-2020 public 09-09-2020).

Logo, sendo a reincidência circunstância preponderante em relação à atenuante da confissão, inviável a compensação entre elas.

Outrossim, cabe observar que o réu é reincidente por furto e por grave crime contra o patrimônio (roubo simples e majorado), o que revela não ser suficiente a integral compensação entre as circunstâncias.

Afora isso, verifica-se a existência de quatro condenações anteriores em desfavor do acusado, todas aptas a configurar a reincidência, o que desautoriza a concessão da compensação.

E, neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"... A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que, se tratando de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade..." (HC 531.187/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)..." (AgRg no HC 663.271/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

"...Tratando-se de réu multirreincidente, cabível a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta três condenações transitadas em julgado, tendo sido utilizada uma para negativar os antecedentes e duas para reconhecer a reincidência..." (AgRg no HC n. 626.637/SC, relator Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021).

Assim, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, e à vista do iter criminis percorrido pelo acusado e

seus comparsas, que efetivamente cortaram a extremidade do cabo elétrico na superfície do solo, tendo o réu escalado o poste para alcançar a altura aproximada de 3,5m (laudo pericial a p. 229), percorrido, pois, a quase totalidade do iter, diminuo a pena 1/3 (um terço), fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não haver circunstância que a modifique.

Apesar do quantum de pena aplicada, ante a reincidência do acusado, representada por quatro condenações, três delas por crimes contra o patrimônio, e evidenciados os maus antecedentes e as circunstâncias desfavoráveis do crime, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, pois necessário será que se submeta à terapêutica penal para oportuna reinserção social.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, face a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não havendo informações acerca da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar MARCELO GOMES DE MOURA, qualificado nos autos, à pena 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por incurso nas sanções previstas no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nos termos do disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará o réu com custas processuais correspondentes a 100 (cem) UFESP'S, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Entretanto, e tratando-se de réu a quem se nomeou Defensor Público, é de se presumir que não tenha condições de arcar com o pagamento de custas, razão pela qual há de se observar o previsto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Sem pedido de decretação de prisão preventiva a apreciar, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão condenatória.

Anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 5 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA